刑法16 筆記：不作為犯違法性、未遂與參與形態

> 來源：刑法16 課程字幕 02:05:00 ~ 02:47:25（約）

🕮 法條原文速查

> **§15**（不作為犯）
> I 對於犯罪結果之發生，法律上有防止之義務，能防止而不防止者，與因積極行為發生結果者同。
> II 因自己行為致有發生犯罪結果之危險者，負防止其發生之義務。

> **§24**（緊急避難）
> 因避免自己或他人生命、身體、自由、財產之緊急危難而出於不得已之行為，不罰。

> **§185-3**（酒駕罪）
> → 建議查閱最新六法原文

> **§276**（過失致死罪）
> 因過失致人於死者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。

> **§277**（傷害罪）
> I 傷害人之身體或健康者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。

> **§320**（竊盜罪）
> I 意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。

> **§230**（血親性交罪）
> → 建議查閱最新六法原文（己手犯）

📋 釋字/實務見解原文速查

> （本主題主要涉及學說爭議，無特定大法官釋字）

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「什麼是義務衝突？」	**作為義務 vs 作為義務**的衝突（不作為犯專屬的阻卻違法事由）
「女朋友跟媽媽同時落水是義務衝突？」	**否**，對女朋友無保證人地位 → 非義務衝突
「義務衝突可用緊急避難處理嗎？」	**不行**，因為犧牲無辜且法益等值 → 攻擊型緊急避難的法益衡量過不去
「義務衝突的效果？」	**阻卻違法**（超法規阻卻違法事由）
「不作為犯何時著手？三說？」	①第一救助機會 ②最後救助機會 ③**區分說**（法益已入危險→著手/未入→看行為人反應）
「不作為犯中止未遂適用推車過山坡圖？」	**不適用**。不作為犯中止必須**積極作為**（放棄＝繼續不作為，非中止）
「間接正犯可否以不作為實現？」	**不可以**（優越意思支配與不作為矛盾）→ 改論直接正犯
「共同正犯可否以不作為實現？」	**可以**（如父母合謀餓死嬰兒）
「教唆犯可否以不作為實現？」	**不可以**（不作為教唆他人犯罪→概念衝突）
「有保證人地位者不阻止他人故意犯罪，論正犯還是幫助犯？」	**實務**：有犯意聯絡→共同正犯/無→幫助犯。**學說五說**各有不同

正文

一、不作為犯的違法性：義務衝突

義務衝突的三種可能類型

```
義務衝突的概念整理
│
├── ① 不作為義務 vs 不作為義務 → ✗ 不是義務衝突
│     └ 理由：不做壞事的義務不會互相衝突
│
├── ② 作為義務 vs 不作為義務 → ✗ 用緊急避難解決即可
│     └ 例：救女兒（作為義務）vs 不毀損他人財物（不作為義務）
│
└── ③ 作為義務 vs 作為義務 → ✓ 真正的義務衝突
      └ 例：媽媽帶兩小孩玩水，兩孩同時溺水，只能救一個
      └ 為何不能用緊急避難？→ 攻擊型避難需法益「大於」，但生命等值
      └ → 只好另創「超法規阻卻違法事由」
```

義務衝突四大要件

要件	內容	反面案例
①數個作為義務同時存在	行為人同時負有多個救助義務	女友＋媽媽落水 → ✗（對女友無保證人地位）
②義務間有排斥關係	只能履行其一	媽媽救完第一個孩子後腳抽筋
③履行部分的法益 ≧ 未履行部分	不可棄重就輕	先救狗不救人 → ✗
④局面非可歸責於行為人	不可自己製造衝突	媽媽怒將兩小孩丟入湖中 → ✗（自己造成的）

效果：四要件均符合 → **阻卻違法**，不成立犯罪

進階案例：酒駕抓通緝犯

- 民眾酒駕追通緝犯 → 律師主張義務衝突
- 法院：**不成立義務衝突**
    - 不酒駕＝義務；抓通緝犯＝**權利**（非義務）
- 也不能主張緊急避難（國家司法權非緊急避難可保護的法益）
- 頂多走 §16 **容許錯誤**（行為人誤認酒駕可被允許）

二、不作為犯的未遂

著手時點三說

```
不作為犯的著手
│
├── 第一救助機會理論
│     └→ 錯過第一個救助機會 ＝ 著手
│
├── 最後救助機會理論
│     └→ 錯過最後的拯救機會 ＝ 著手
│
└── 區分說（法益危險理論/直接危險理論）
      ├→ 法益已進入危險狀態 → 著手
      └→ 法益尚未進入危險狀態
            ├→ 行為人隨時可介入作為 → 等危險接近才著手
            └→ 行為人轉身離開 → 離開時即著手
```

> **平交道管理員案**：醉漢倒在鐵軌上
>
> - 火車半小時後才來＋管理員在旁邊 → 等火車逼近才著手
> - 火車半小時後才來＋管理員轉身離開 → **離開時即著手**

中止未遂

- 不作為犯的中止未遂 **不適用**「推手推車過山坡」的圖
- 理由：不作為犯的中止行為必須是**積極作為**（放棄＝繼續不作為，不是中止）

作為犯中止：	不作為犯中止：
未了 → 放棄即可	✗ 放棄 ＝ 繼續不作為
既了 → 積極拯救	✓ 中止必須積極作為

經典考題：小黑狼狗案

甲牽狼狗小黑散步 → 小黑掙脫 → 撕咬乙 → 乙說「做鬼也不會放過你」→ 甲叫小黑停止＋打119

分析三步驟：

1．小黑掙脫狗繩（第一個不作為）
→ 不成立犯罪（無作為可能性：狼狗發瘋力氣比人大）

2．小黑撕咬乙，甲不阻止（第二個不作為）
→ 有作為可能性 → 討論著手問題
→ 三說分析各有不同結論

3．中止未遂（甲最終阻止＋打119）
→ 己意性？（被害人威脅「做鬼也不放過你」）
→ 主觀說（法蘭克公式）：得為而不為 → ✓ 己意
→ 限定主觀說：倫理自我要求 → ✗ 可能不算
→ 準中止犯（被路人送醫，因果偏離）

三、不作為犯的參與形態

參與形態 × 不作為
│
├── 間接正犯 → ✗ 不可以
│　└ 理由：優越意思支配 ≠ 不作為（概念矛盾）
│　└ 出現疑似不作為間接正犯 → 改論直接正犯
│
├── 共同正犯 → ✓ 可以
│　└ 例：父母合謀餓死嬰兒 → 不作為殺人共同正犯
│
├── 教唆犯 → ✗ 不可以
│　└ 理由：不作為教唆他人犯罪 → 概念上衝突
│
└── 幫助犯 → ✓ 可以
　└ 例：警衛故意不設保全 → 不作為幫助竊盜

搬家筆電案（間接正犯 × 不作為）

甲畢業搬家 → 朋友誤將室友筆電裝箱 → 甲知情但不阻止

分析層次：
① 間接正犯？→ ✗（不作為不能成立間接正犯）
② 直接正犯？→ ✗（甲對室友財產無保證人地位：無保護義務＋無監督義務）
③ 結論：無罪

四、★ 核心爭點：不作為正犯 vs 不作為幫助犯的區分

前提辨明

有保證人地位者不阻止他人犯罪
│
├── 他人犯「過失」犯罪 → 保證人論【直接正犯】（無爭議）
│　└ 理由：過失行為不能論幫助犯
│　└ 例：護校生注射錯藥＋指導護理師不阻止 → 護理師論故意殺人正犯
│
└── 他人犯「故意」犯罪 → 保證人論正犯還是幫助犯？（★核心爭點）
　└ 例：人學老爸案（兒子被流氓打，爸爸不阻止）

六說比較總覽

學說	區分標準	人學老爸案結論	代表學者
實務見解	有無犯意聯絡	有→共同正犯/無→**幫助犯**	實務

①犯罪支配論	保證人能否獨自阻止犯罪	分三種情況（見下）	德國學說
②主觀理論	為誰的利益不作為	為己→正犯/為他人→幫助犯	德國學說
③正犯理論	違反義務＝正犯（原則）	**正犯**（除三例外）	許澤天
④幫助犯理論	擺爛者永遠非主角	**幫助犯**（無例外）	蕭宏義
⑤區別理論	違反保護義務→正犯/違反監督義務→幫助犯	依義務類型判斷	林書楷

> **重要**：學說所講的「正犯」＝**單獨正犯**（非共同正犯），因通常保證人與作為犯之間無犯意聯絡

①犯罪支配論（三種情況）

情況	說明	結論	人學老爸案舉例
有作為也沒用	結果不可避免	**不罰**	爸爸像老師體型 vs 流氓像館長＋荒郊野外
無法獨自阻止但可求助	可透過第三方阻止	**幫助犯**	爸爸像老師體型 vs 流氓像館長＋但在熱鬧市區
自己就能阻止	有能力中止卻不中止	**正犯**	爸爸像館長體型 vs 流氓像老師體型

③正犯理論的三個例外

正犯理論原則：不作為犯**原則上都是正犯**，但三個例外改論幫助犯：

例外	說明
純正身分犯	行為人不具身分 → 不能論正犯
己手犯	如血親性交罪（爸爸放任兄妹性交 → 不能論血親性交正犯 → 論幫助犯）
意圖犯而欠缺意圖	要有特定意圖才能成立的犯罪，行為人欠缺該意圖 → 論幫助犯

⑤區別理論

```
不作為的行為人違反何種義務？
│
├── 違反「保護義務」→ 離法益近 → 正犯
│     例：被霸凌學生的父親不阻止 → 正犯（對兒子有保護義務）
│
└── 違反「監督義務」→ 離法益遠 → 幫助犯
      例：班導師不阻止霸凌 → 幫助犯（對霸凌者有監督義務）
```

★ 經典考題：警衛丙案（105年警特）

```
甲欲偷乙家古董花瓶 → 對警衛丙說：我代班 → 丙知情且對花瓶有興趣 → 配合甲的計畫

丙的刑事責任（六說分析）：

實務：丙與甲無犯意聯絡 → 幫助犯
①犯罪支配論：丙上班就能阻止 → 正犯（單獨）
②主觀理論：丙為自己利益（想要花瓶）→ 正犯
③正犯理論：違反義務→原則正犯（須檢查三例外，竊盜非身分犯/己手犯/有不法所有意圖→無例外→正犯）
④幫助犯理論：一律幫助犯
⑤區別理論：丙違反對住戶財產的保護義務 → 正犯

結論：除實務＋幫助犯理論外，其餘學說均論正犯
```

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§15 I	不作為犯保證人義務	核心條文
§15 II	危險前行為	保證人地位
§24	緊急避難	義務衝突 vs 緊急避難
§16	禁止錯誤	酒駕抓通緝犯案
§276	過失致死	不作為過失致死
§277	傷害罪	人學老爸案
§320	竊盜罪	警衛丙案

關鍵實務見解速查表

實務見解	要旨
實務（不作為正犯 vs 幫助犯）	有犯意聯絡→共同正犯；無犯意聯絡→幫助犯